



Apelação nº. 0803817-76.2023.8.19.0083 **PJe**
Órgão: JAPERI 2ª VARA

FLS.1

Apelante: VAGNER DOS SANTOS MORAIS

Advogado: DEFENSORIA PÚBLICA

Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Relator: DES. JOAQUIM DOMINGOS DE ALMEIDA NETO

EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. DENÚNCIA ANÔNIMA. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DA PRÁTICA DELITIVA. AUSÊNCIA DE INVESTIGAÇÕES PRÉVIAS E DE FUNDADAS RAZÕES. ILEGALIDADE. NULIDADE DA PROVA OBTIDA E DAQUELAS DELA DERIVADAS. ABSOLVIÇÃO DECRETADA. RECURSO PROVIDO. IMPÕE. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME.

1. Recurso defensivo em razão da condenação do réu pela prática do delito previsto no artigo 16, §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO.

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se houve violação de domicílio; e (ii) se há prova suficiente para a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. No caso dos autos, restou caracterizada a violação da garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar.

4. Sabe-se que o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral é no sentido de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados” [STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, j: 8/10/2010].

5. Na hipótese, a diligência decorreu de denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos de crime, não legitimando o ingresso de policiais no domicílio do réu, estando, ausente, assim, a justa causa.



Apelação nº. 0803817-76.2023.8.19.0083 **PJe**
Órgão: JAPERI 2ª VARA

FLS.2

6. Por certo, os policiais militares, conscientemente, optaram pela diligência exploratória, sem a necessária ciência prévia da efetiva ocorrência de crime permanente, contaminando assim toda a sua atuação posterior.

7. Assim, ainda que se trate de crime permanente, necessária é a existência de fundamentos razoáveis anteriores à busca para justificar o ingresso na residência do agente sem autorização judicial, o que não se verificou na espécie. Não houve, *in casu*, condição alguma prévia que demonstrasse que o apelante estivesse praticando algum crime no interior da sua residência, motivada a incursão policial por meio de meras “informações” anônimas.

8. Nesse contexto, constatada a ilegalidade do ingresso dos policiais na residência do réu sem prévia autorização judicial, devem ser declaradas ilícitas as provas colhidas.

9. Diante desse cenário, é impositiva a absolvição do apelante, com fulcro no artigo 386, II, do Código de Processo Penal. Prejudicados os demais pleitos defensivos.

IV. DISPOSITIVO.

10. PROVIMENTO DO RECURSO. ABSOLVIÇÃO.

Jurisprudências citadas: STJ: REsp 2114620 / MG, Relator Ministro JESUÍNO RISSATO, Órgão Julgador T6 - SEXTA TURMA, Data do Julgamento 09/04/2024, Data da Publicação/Fonte DJe 12/04/2024; AgRg no HC 727004 / RJ, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA, Data do Julgamento 30/10/2024, Data da Publicação/Fonte DJe 05/11/2024; AgRg no HC 770572 / GO, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA, Data do Julgamento 06/12/2022, Data da Publicação/Fonte DJe 14/12/2022; HC n. 512.418/RJ, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 26/11/2019, DJe de 3/12/2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de **Apelação Criminal nº 0803817-76.2023.8.19.0083**, em que são partes as acima indicadas, **A C O R D A M** os Desembargadores que compõem a 7ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, por **unanimidade**, em **dar provimento ao recurso para reconhecer a ilicitude das provas obtidas por meio de violação de domicílio e dela derivadas, por conseguinte, absolver o recorrente, com fulcro no art. 386, II, do CPP**, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Rio de Janeiro, na data constante da assinatura digital.

Desembargador **Joaquim Domingos de Almeida Neto**
Relator



Apelação nº. 0803817-76.2023.8.19.0083 **PJe**
Órgão: JAPERI 2ª VARA

FLS.3

Apelante: VAGNER DOS SANTOS MORAIS

Advogado: DEFENSORIA PÚBLICA

Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Relator: DES. JOAQUIM DOMINGOS DE ALMEIDA NETO

R E L A T Ó R I O

VAGNER DOS SANTOS MORAIS, devidamente qualificado e representado nos autos, foi denunciado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO perante o JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE JAPERI, porquanto, segundo consta da exordial acusatória (index 88866802 do PJe):

No dia 16 de novembro de 2023, aproximadamente às 08h30min, na Rua Dona Célia, nº 169, Parque Santos/ Engenheiro Pedreira, nesta comarca, o **DENUNCIADO**, consciente e voluntariamente, **possuía e tinha em depósito uma arma de fogo com numeração suprimida**, a saber, 01 (um) revólver, marca Rossi, calibre .38, desmuniado, **além de possuir 30 (trinta) munições, calibre .38**, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consoante autos de apreensão de ids. 87867292 e 87867291 e laudos periciais a serem oportunamente juntados aos autos.

Por ocasião dos fatos, policiais militares foram comunicados por meio do disque-denúncia (DD14446.11.2023) que o **DENUNCIADO** andava armado e vendia cigarros contrabandeados, sendo informado ainda o seu local de atuação.

Desta forma, aproveitando-se de uma operação policial, os policiais militares foram até a residência do **DENUNCIADO** e o chamaram no portão, sendo por ele atendidos, passando os policiais a comunicar os fatos a ele atribuídos.

No momento em que ouviu os fatos o **DENUNCIADO** negou que os tivesse praticado, todavia, posteriormente, apresentou voluntariamente aos policiais militares a arma de fogo e as munições anteriormente descritas.

Diante do narrado, conclui-se que foram objetiva e subjetivamente típicas, ilícitas e culpáveis as condutas praticadas pelo **DENUNCIADO**, inexistindo quaisquer descriminantes a justificá-las, estando ele, por conseguinte, incurso nas penas do **artigo 16, §1º, I, da Lei 10.826/03**.

A denúncia teve por suporte as seguintes peças processuais: registro de ocorrência e aditamento (index 87867287 e 87867293), termos de declaração (index 87867289 e 87870551), autos de apreensão (index 87867291 e 87867292), auto de prisão em flagrante (index 87867287), e laudos de exame em arma de fogo e em munições (index 117901215 e 117901209).

Recebimento da denúncia no dia 24/11/2023 (index 89072274).



Apelação nº. 0803817-76.2023.8.19.0083 **PJe**
Órgão: JAPERI 2ª VARA

FLS.4

Decisão no dia 19/12/2023 revogando a prisão preventiva do réu, com aplicação de medidas cautelares (index 94239780).

Cumprimento do alvará de soltura no dia 20/12/2023 (index 95524433).

FAC apontando a primariedade do réu (index 123954699).

Sentença (index 164779718), julgando procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o réu VAGNER DOS SANTOS MORAIS, como incurso nas penas do artigo 16, §1º, IV da Lei 10.826/03, às penas de 03 (três) anos de reclusão, a ser cumprida no regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, com substituição por duas restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços à comunidade prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário-mínimo.

A dosimetria foi estabelecida da seguinte forma:

PRIMEIRA FASE

A culpabilidade do réu é normal para o tipo. Não há notícias de maus antecedentes, bem como de elementos que permitam a análise da conduta social e da personalidade. Os motivos, as circunstâncias e as consequências são inerentes ao tipo. O comportamento da vítima não é passível de valoração, pois o crime em espécie tem como sujeito passivo a coletividade.

Diante disso, fixo a **pena-base**, no mínimo legal, em **3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, à razão do mínimo legal.**

SEGUNDA FASE

Incide, nesta fase, a atenuante da confissão, prevista no artigo 65, III, “d” do Código Penal, já que o réu, nos termos do enunciado nº 545 da súmula do STJ, confessou a prática do crime. Todavia, em atenção ao enunciado nº 231 da súmula do STJ, mantenho a pena fixada na fase anterior, vale dizer, em **3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, à razão do mínimo legal.**

TERCEIRA FASE

Não incidem causas de aumento ou diminuição, razão por que **torno a pena definitiva em 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, à razão do mínimo legal.**

Fixo o regime **aberto** para início de cumprimento de pena, nos termos do artigo 33, §2º, “c” do Código Penal, já considerado o que determina o §2º do artigo 387 do CPP, incluído pela Lei 12.736/2012.

O réu preenche os requisitos previstos nos incisos I, II e III do artigo 44 do Código Penal, razão pela qual **substituo a pena privativa de liberdade aplicada por duas restritivas de direitos, vale dizer, prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, no valor de 1 (um) salário-mínimo, dividido em até 10 (dez) parcelas mensais e sucessivas, que deverão ser pagas a entidade a ser determinada pelo Juízo de execução.**



Apelação nº. 0803817-76.2023.8.19.0083 **PJe**
Órgão: JAPERI 2ª VARA

FLS.5

Deixo de estipular a reparação de danos prevista no artigo 387, IV, do CPP, porquanto o crime tratado nos presentes autos tem sujeito passivo indeterminado. Ademais, ainda que assim não fosse, o tema não foi analisado sob o crivo do contraditório.

Condeno o réu ao pagamento das custas, na forma do artigo 804 do CPP. Ressalto que eventual isenção deve ser requerida ao Juízo de execução, nos termos do verbete sumular nº 74 do Egrégio TJRJ.

Inconformada com o édito condenatório, a Defensoria Pública interpôs recurso de apelação. Nas razões recursais, a defesa busca, em linhas gerais, a absolvição do delito, por inconstitucionalidade da tipificação de crimes de perigo abstrato em respeito aos princípios de presunção de inocência e *in dubio pro reo*, bem como por insuficiência de provas, na forma do art. 386, inciso VII. do CPP. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da atenuante de confissão com a fixação da pena mesmo aquém do mínimo legal e a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Apresenta prequestionamento (index 184702372).

Em contrarrazões (index 191400200), o Ministério Público requereu seja julgado improcedente o recurso, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pela Dra. Taciana Dantas Carpilovsky, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso defensivo (pasta 08).

É o relatório, que encaminhei à douta Revisão.

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Ab initio, cabe desde logo refutar a tese defensiva de inconstitucionalidade da tipificação de crimes de perigo abstrato.

O entendimento consolidado no STJ é no sentido de que “Tanto a posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei n. 10.826/2003) quanto o porte ou posse de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da mesma lei) são crimes de perigo abstrato, dispensando-se prova de efetiva situação de risco ao bem jurídico tutelado” (AgRg no AREsp 1.027.337/MT, Quinta Turma, de minha relatoria, DJe 27/03/2017).

Colaciono o seguinte julgado na mesma linha de inteligência:



Apelação nº. 0803817-76.2023.8.19.0083 **PJe**

FLS.6

Órgão: JAPERI 2ª VARA

Ementa. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ATIPICIDADE. ARTEFATO DESMUNICIADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. DELITO DE PERIGO ABSTRATO. MUNIÇÕES DESACOMPANHADAS DE ARMAMENTO. CONDUTA TÍPICA. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA. REGIME PRISIONAL INICIAL. ABRANDAMENTO EM RELAÇÃO A UM DOS RÉUS. ORDEM CONCEDIDA EM MENOR EXTENSÃO.

1. Em relação ao porte de arma de fogo desmuniada, esta Corte Superior **uniformizou o entendimento - alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - de que o tipo penal em apreço é de perigo abstrato. Precedentes.**

2. **Não há falar em atipicidade material da conduta atribuída à acusada Renata de Souza Garcia, porque o simples fato de possuir, sob sua guarda, arma (dois revólveres com numeração suprimida) à margem do controle estatal - artefato que mesmo desmuniado possui potencial de intimidação e reduz o nível de segurança coletiva exigido pelo legislador - caracteriza o tipo penal previsto no art. 16, parágrafo único, I, do Estatuto do Desarmamento, principalmente porque o bem jurídico tutelado pela norma penal não é a incolumidade física de outrem, mas a segurança pública e a paz social, efetivamente violadas.**

3. No que tange à posse de munições desacompanhadas do artefato capaz de dispará-las, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.699.710/MS, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, e do AgInt no REsp n. 1.704.234/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, alinhou-se ao entendimento da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal e passou a reconhecer a atipicidade material da conduta (princípio da insignificância) em situações específicas de ínfima quantidade de munição, aliada à ausência do artefato capaz de disparar o projétil, que denote a incapacidade de gerar perigo à incolumidade pública.

4. A situação dos autos é diversa, pois a ré Vanessa da Silva Castro e um dos corréus guardavam em sua residência, além de 17 munições de uso restrito (9 mm), cerca de 20 kg de maconha, divididos em 24 tabletes. Assim, a moldura fática é clara ao demonstrar situação em que, a despeito de não haver sido apreendido armamento na residência da paciente, os materiais ilícitos localizados em sua moradia permitem verificar a potencial lesividade de sua conduta, a justificar a condenação pela posse ilegal das munições de uso restrito.

5. Uma vez reconhecida, incidentalmente, a inconstitucionalidade do óbice contido no § 1º do art. 2º da Lei n. 8.072/1990 (STF, HC n. 111.840/ES, DJe 17/12/2013), a escolha do regime inicial de cumprimento de pena deve levar em consideração a quantidade da reprimenda imposta, a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, bem como as demais peculiaridades do caso concreto (por exemplo, a quantidade, a natureza e/ou a diversidade de drogas apreendidas), para que, então, seja fixado o regime carcerário que se mostre o mais adequado para a prevenção e a repressão do delito perpetrado, nos termos do art. 33 e parágrafos do Código Penal - com observância também ao disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006.



Apelação nº. 0803817-76.2023.8.19.0083 **PJe**
Órgão: JAPERI 2ª VARA

FLS.7

6. Quanto à paciente Renata de Souza Garcia, as penas-base para os dois crimes pelos quais foi condenada (tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito) foram impostas no mínimo legal e a reprimenda a ela definitivamente imposta não é superior a 8 anos de reclusão. Além disso, a Corte estadual deixou de mencionar elementos concretos dos autos para evidenciar a elevada periculosidade da acusada ou a acentuada reprovabilidade de sua conduta, de modo que o regime semiaberto é o mais adequado para a prevenção e a repressão dos delitos praticados, nos termos do art. 33, § 2º, "b", e § 3º, do Código Penal.

7. No que toca ao réu Romário Silva Gomes, a pena-base, pelo crime de tráfico de drogas, foi estabelecida acima do mínimo legal, diante da valoração negativa das circunstâncias do delito (quantidade de droga apreendida - cerca de 81 kg de maconha). Assim, nota-se a indicação de circunstância concreta a evidenciar a maior gravidade da conduta por ele perpetrada, a justificar a imposição do modo mais gravoso, consoante disposto no art. 33, § 3º, do Código Penal.

8. Ordem concedida, em menor extensão, a fim de fixar o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena imposta à paciente Renata de Souza Garcia. (HC 447071 / MS, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Órgão Julgador T6 - SEXTA TURMA, Data do Julgamento 14/08/2018, Data da Publicação/Fonte DJe 29/08/2018).

Logo, descabido se falar em inconstitucionalidade dos crimes de perigo abstrato.

Lado outro, no caso dos autos, compreendo que foi **ilícito** o ingresso no domicílio do acusado.

Consta do auto de prisão em flagrante a seguinte dinâmica fática (index 87867286):

Trata-se de Auto de Prisão em Flagrante (APF) lavrado em desfavor de VAGNER DOS SANTOS MORAIS.

De acordo com o policial José Tiago de Souza:

Que no dia de hoje, 16/11/2023, estava de serviço no 24º BPM quando por volta das 08:30 h participou de uma operação policial na comunidade do São Jorge, em Japeri; Que com base no disque denúncia DD14446.11.2023 que relatava que o nacional VAGNER DOS SANTOS MORAIS anda armado, vende cigarros contrabandeados informando o seu local de atuação; Que aproveitando da operação policial, foram até a residência do suspeito, localizada na Rua Dona Celia 169 e o chamaram no portão, momento em que foram atendidos pelo próprio; Que a partir de então expuseram a denúncia que tinha a seu desfavor tendo Vagner negado inicialmente, contudo voluntariamente apresentou um revólver Rossi calibre .38 com numeração suprimida e desmuniado, além de 30 munições; Que diante do exposto encaminharam Vagner juntamente com os bens apreendidos a 63ª DP e posteriormente a esta central de flagrantes. E mais não disse.



Apelação nº. 0803817-76.2023.8.19.0083 **PJe**
Órgão: JAPERI 2ª VARA

FLS.8

Por oportuno, colaciono os depoimentos prestados em sede policial pelos policiais militares Guilherme Toscano de Britto e José Tiago de Souza, respectivamente:

QUE o declarante comparece a esta unidade para noticiar que estava em efetivo serviço na data de 16NOV2023 quando, por volta das 08h30min, e estava em operação pelo 24º BPM na Comunidade do São Jorge, São Jorge, Japeri / RJ; QUE a equipe de buscas, após o levantamento de dados de inteligência, com base no DD 14446.11.2023, logrou êxito em encontrar VAGNER DOS SANTOS MORAIS em sua residência cito RUA DONA CELIA, 169, SÃO JORGE, JAPERI / RJ; QUE o declarante afirma ter chamado no respectivo endereço o nacional WAGNER tendo este vindo atendê-lo; QUE o declarante informou do DD a ele em seu desfavor, afirmando haver materiais ilícitos, tendo WAGNER negado tal fato; QUE WAGNER, porém, apresentou voluntariamente um REVÓLVER ROSSI, CAL. 38, NUMERAÇÃO SUPRIMIDA (desmuniado), bem como 30 (trinta) munições (não estavam no tambor), dizendo ser de sua propriedade há 4 (quatro) anos e que não soube informar de quem comprou; QUE, diante do fato, compareceu de imediato a esta dp para noticiar a autoridade responsável.

Que no dia de hoje, 16/11/2023, estava de serviço no 24º BPM quando por volta das 08:30 h participou de uma operação policial na comunidade do São Jorge, em Japeri; Que com base no disque denúncia DD14446.11.2023 que relatava que o nacional VAGNER DOS SANTOS MORAIS anda armado, vende cigarros contrabandeados informando o seu local de atuação; Que aproveitando da operação policial, foram até a residência do suspeito, localizada na Rua Dona Celia 169 e o chamaram no portão, momento em que foram atendidos pelo próprio; Que a partir de então expuseram a denúncia que tinha a seu desfavor tendo Vagner negado inicialmente, contudo voluntariamente apresentou um revólver Rossi calibre .38 com numeração suprimida e desmuniado, além de 30 munições; Que diante do exposto encaminharam Vagner juntamente com os bens apreendidos a 63ª DP e posteriormente a esta central de flagrantes. E mais não disse.

Vejamos a prova oral coligida em juízo ao feito e reproduzida na sentença condenatória, *in verbis*:

“O policial militar Guilherme Toscano de Britto disse (depoimento disponível no PJe mídias), em síntese, que: recorda dos fatos; estava em uma operação de combate ao tráfico de drogas na localidade; os policiais perceberam que a comunidade estava estabilizada em relação ao tráfico de drogas e decidiram aproveitar para verificar uma denúncia; a denúncia informava que um indivíduo estava na posse de arma de fogo e cigarros contrabandeados; os policiais foram a residência do indivíduo, que era o réu, e tocaram a companhia; os policiais foram atendidos pelo réu e informaram a ele sobre os fatos; o réu ficou surpreso com as informações e afirmou que “não trabalhava com isso”; o réu franqueou a entrada dos policiais e permitiu revistarem seu carro, pois a denúncia informava que o réu possuía carro e moto; verificou que não existia nada no portal sobre os



Apelação nº. 0803817-76.2023.8.19.0083 **PJe**
Órgão: JAPERI 2ª VARA

FLS.9

veículos do réu; **o réu trouxe uma bolsa de sua casa e disse que o único material ilícito era uma arma de fogo, que estava no interior da bolsa; foi encontrado uma arma de fogo e algumas munições;** o réu não sabia da procedência e de quem foi comprado; o réu foi conduzido à delegacia e foi registrado o flagrante; os policiais aproveitam as operações para verificar as denúncias dentro de áreas vermelhas; a denúncia referente aos fatos teve origem do Disque Denúncia; a denúncia informava o nome completo do réu e seus dados pessoais, que fazia entregas de itens contrabandeados, que andava armado; a denúncia também informava algo ilícito sobre a procedência de seu veículo; **não constatou nada de ilícito, além da arma de fogo; o réu foi receptivo, educado, permitiu a entrada dos policiais em sua casa e em seu carro o réu apresentou a arma de fogo voluntariamente;** não foi realizada busca na residência do réu; não recorda se a arma de fogo estava muniçada, mas viu uma quantidade de munição, que ia além da capacidade da arma; a arma de fogo aparentava estar em um estado “muito bom” de conservação, mas com a numeração suprimida.”

“**O réu, Vagner dos Santos de Carvalho,** disse (depoimento disponível no PJe mídias), em síntese, que: os fatos atribuídos a ele não são verdadeiros; **a arma de fogo encontrada pertencia ao seu falecido pai; a arma era antiga e estava enferrujada;** é nascido e criado na localidade dos fatos; **seu pai é falecido há 4 (quatro) anos; manteve a arma de fogo guardada, pois a considerava uma herança e um meio de defesa,** por residir em uma área de risco, onde já foi assaltado.”

Com efeito, após a detida análise da oitiva do depoimento do PM Guilherme Toscano de Britto pelo sistema PJeMídia, constato que os policiais militares estavam em uma operação na localidade para apurar o tráfico de drogas, que tal operação não guardava nenhuma relação com os fatos narrados na denúncia e que após a realização da referida operação decidiram aproveitar “o endereço” para verificar a denúncia.

Mencionou que o Disque Denúncia indicava que o réu andava armado, contrabandeava cigarro e veículos. Relatou que o réu franqueou a entrada dos policiais e que “**NÃO FOI CONSTATADO NADA DE ILÍCITO, EXCETO O QUE ELE APRESENTOU VOLUNTARIAMENTE**”.

Como visto, após a entrada dos policiais militares na sua residência e da não constatação de nenhuma ilegalidade, o réu entregou voluntariamente uma bolsa com uma arma de fogo e munições, o que deu origem ao processo ora em epígrafe.



Apelação nº. 0803817-76.2023.8.19.0083 PJe
Órgão: JAPERI 2ª VARA

FLS.10

Importante ressaltar que o referido Disque Denúncia não se encontra acostado aos presentes autos.

A despeito de o réu ter afirmado em juízo que a arma de fogo pertencia ao seu falecido pai e que a guardava por herança e a considerava como meio de defesa, na hipótese não restou demonstrado a existência de elementos mínimos concretos que apontassem para o caso de flagrante delito.

Depreende-se dos excertos acima que policiais receberam denúncia anônima dando conta do porte de arma e contrabando desempenhados pelo acusado, razão pela qual dirigiram-se até sua residência e lá ingressaram, oportunidade em que não constataram nenhuma ilegalidade, tendo na sequência o réu, voluntariamente, entregue uma bolsa com a arma de fogo e munições.

Por certo, não houve qualquer referência à prévia investigação, monitoramento ou campanas no local, a afastar a hipótese de que se tratava de averiguação de informações robustas, detalhadas e atuais acerca da existência de materiais ilícitos naquele lugar. Ao contrário, o policial militar Guilherme Toscano de Britto foi enfático ao afirmar que como estavam na localidade e decidiram aproveitar “o endereço” para verificar a denúncia.

Conscientemente, optaram pela diligência exploratória, sem a necessária ciência prévia da efetiva ocorrência de crime permanente, contaminando assim toda a sua atuação posterior.

Sabe-se que tanto o crime de posse, porte, guarda ou ocultação de drogas é de natureza permanente, cuja consumação se prolonga no tempo, desta forma, enquanto o agente mantém em sua guarda armas e munição ou se mantém associado para a prática da traficância estará em estado de flagrância, permitindo sua prisão em flagrante, independentemente de mandado de busca e apreensão.

No entanto, não se pode admitir tomada de tal assertiva como regra plana para toda e qualquer situação. “Est modus in rebus”.

Volte-se ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral, “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados” [STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, j: 8/10/2010].

Assim, ainda que se trate de crime permanente, necessária é a existência de fundamentos razoáveis anteriores à busca para justificar o ingresso na residência do



Apelação nº. 0803817-76.2023.8.19.0083 **PJe**

FLS.11

Órgão: JAPERI 2ª VARA

agente sem autorização judicial, o que não se verificou na espécie. Não houve, in casu, condição alguma prévia que demonstrasse que o apelante estivesse praticando algum crime no interior da sua residência, motivada a incursão policial por meio de meras “informações” anônimas.

Da mesma forma, cabe enfatizar que não se fez menção a nenhuma atitude suspeita, externalizada em atos concretos, tampouco movimentação indicativa da realização de práticas ilícitas na residência do acusado, eventos por si só suficientes para configurar a fundadas razões para se concluir que havia flagrante delito em andamento, bem como a autorizar o ingresso em domicílio sem autorização judicial.

Verifica-se, assim, a ausência de justa causa para amparar o flagrante, conforme orientação externada no julgamento pelo STJ do HC 598.051/SP, em voto do Ministro Rogério Schietti. Na mesma linha, cito o HC 616.584/RS, QUINTA TURMA, julgado em 30/03/2021, DJe 06/04/2021.

Ademais, considerando os elementos do caso em questão, entendo que soa inverossímil a versão policial, ao narrar que o acusado, após espontaneamente autorizar o ingresso na sua residência e da não constatação de nenhuma ilegalidade, entregou voluntariamente uma bolsa contendo uma arma de fogo e 18 munições. Ora, um mínimo de vivência e de bom senso sugerem a falta de credibilidade de tal versão. Pelas circunstâncias em que ocorreram os fatos, somado à notícia anônima de que havia na residência uma clara situação de práticas delitivas, não se mostra crível a voluntariedade e a liberdade para consentir na realização das diligências e na entrega dos objetos ilícitos.

Se, de um lado, se deve, como regra, presumir a veracidade das declarações de qualquer servidor público, não se há de ignorar, por outro lado, que o senso comum e as regras de experiência merecem ser considerados quando tudo indica não ser crível a versão oficial apresentada, máxime quando interfere em direitos fundamentais do indivíduo e quando se nota indisfarçável desejo de se criar narrativa amparadora de uma versão que confira plena legalidade à ação estatal.

Respalado pelos precedentes acima, entendo que houve ilegalidade na apreensão realizada, uma vez que os policiais ingressaram na residência do acusado sem qualquer evidência clara de prática delitiva, não havendo fundadas razões para o procedimento desprovido de mandado judicial. Por decorrência, tem-se a ilicitude dos elementos probatórios ali colhidos.

Restou, pois, caracterizada a violação da garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar.

Apelação nº. 0803817-76.2023.8.19.0083 **PJe**
Órgão: JAPERI 2ª VARA

FLS.12

Nesse contexto, constatada a ilegalidade do ingresso dos policiais na residência do réu sem prévia autorização judicial, devem ser declaradas ilícitas as provas colhidas.

Apoiada a condenação pela prática do delito descrito no artigo 16, §1º, inciso IV, da Lei 10.826/03 unicamente nas provas acima referenciadas, declaro a nulidade da apreensão da arma de fogo e das munições, advinda da violação de domicílio acima mencionada, e, por derivação, de todo o caderno probatório angariado nos autos, conquanto indefectivelmente contaminadas, impondo-se a absolvição do acusado, nos termos do art. 386, II, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados do STJ:

Ementa. RECURSO ESPECIAL. CRIME DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. CRIME PERMANENTE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. SOMENTE DENÚNCIA ANÔNIMA. ILEGALIDADE RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ABSOLVIÇÃO DO RECORRENTE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. Nos crimes permanentes, tal como o tráfico de entorpecentes e posse ilegal de arma e munições, o estado de flagrância protraí-se no tempo, o que não é suficiente, por si só, para justificar a busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, há uma situação de flagrante delito em desenvolvimento.

2. Consoante julgamento do RE n. 603.616/RO, pelo Supremo Tribunal Federal, não é necessária certeza quanto à ocorrência da prática delitiva para se admitir a entrada em domicílio, bastando que, em compasso com as provas produzidas, seja demonstrada a justa causa na adoção medida, ante a existência de elementos concretos que apontem para o flagrante delito.

3. Caso concreto em que não foram realizadas investigações prévias nem indicados elementos concretos robustos a indicar a existência de posse irregular de arma de fogo no interior da residência, tampouco comprovou-se ter havido o consentimento do morador para o ingresso no local, o que torna ilícita toda a prova obtida com a invasão de domicílio.

4. Recurso especial provido para reconhecer a ilicitude da busca e apreensão domiciliar e das provas dela decorrentes e, em consequência, absolver o recorrente. (REsp 2114620 / MG, Relator Ministro JESUÍNO RISSATO, Órgão Julgador T6 - SEXTA TURMA, Data do Julgamento 09/04/2024, Data da Publicação/Fonte DJe 12/04/2024).

Ementa. PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM O CONSENTIMENTO DO MORADOR, MANDADO JUDICIAL OU INVESTIGAÇÃO PRÉVIA ANTERIOR. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NULIDADE RECONHECIDA. ILICITUDE DAS PROVAS DAÍ DECORRENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL - MPF DESPROVIDO.

1. "O ingresso em moradia alheia depende, para sua validade e sua regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contex

Apelação nº. 0803817-76.2023.8.19.0083 **PJe**
Órgão: JAPERI 2ª VARA

FLS.13

anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio" (AgRg no HC 653.943/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 8/6/2021, DJe 14/6/2021).

No caso em debate, depreende-se que os indícios sobre a possível prática do delito do art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n. 10.826/03 no interior da residência do paciente eram muito frágeis, não restando caracterizado o elemento "fundadas razões".

2. Colhe-se que os policiais no dia dos fatos procederam ao local após denúncia de que o ora agravado teria participado de um homicídio no Bairro Siderlândia e estaria na porta de sua casa. No local, identificaram outro elemento de nome Denis, primo do acusado, o qual, informa os policiais que autorizou a entrada da guarnição na casa de Rodrigo, ora agravado. Os policiais ingressaram e procederam a busca em sua residência. Foram encontradas 1 arma de fogo calibre 9mm e 16 munições de mesmo calibre na churrasqueira. Nessa ordem de ideias, **não havia elementos objetivos e concretos que justificassem a invasão de domicílio. O ingresso dos policiais no domicílio decorreu unicamente de denúncia anônima genérica e sem nenhuma especificação, ausente prévia investigação, monitoramento ou campanhas no local, ou a presença de circunstância concreta que sinalizasse a ocorrência de flagrante delito no interior da residência. Dado que a casa é asilo inviolável do indivíduo, desautorizado estava o ingresso na residência do paciente, de maneira que as provas obtidas por meio da medida invasiva são ilícitas, bem como todas as que delas decorreram (por força da Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada), o que impõe a absolvição do acusado.**

3. Agravo regimental do Ministério Público Federal desprovido. (AgRg no HC 727004 / RJ, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA, Data do Julgamento 30/10/2024, Data da Publicação/Fonte DJe 05/11/2024).

Ementa. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. DENÚNCIAS ANÔNIMAS. PATRULHAMENTO. FUGA DO SUSPEITO. AUTORIZAÇÃO DA ENTRADA. LIVRE E SEM VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. ILICITUDE DAS PROVAS DAÍ DECORRENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. **Como é de conhecimento, o Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE 603.616, Rel. Ministro GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 5/11/2015, Repercussão Geral - Dje 9/5/1016 Public. 10/5/2016).**

2. Nessa linha de raciocínio, o ingresso em moradia alheia depende, para sua validade e sua regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio.

3. A existência de denúncia anônima de tráfico de drogas no local associada ao avistamento de um indivíduo correndo para o interior de sua residência não constituem fundamento suficiente para autorizar a conclusão de que, na residência em

Apelação nº. 0803817-76.2023.8.19.0083 **PJe**
Órgão: JAPERI 2ª VARA

FLS.14

estava sendo cometido algum tipo de delito, permanente ou não. Necessária a prévia realização de diligências policiais para verificar a veracidade das informações recebidas (ex: "campana que ateste movimentação atípica na residência").

Precedentes do STJ: AgRg no RHC n. 149.964/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 16/11/2021; HC n. 609.955/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 2/2/2021, DJe de 8/2/2021.

4. **Na hipótese, não houve qualquer referência à prévia investigação, monitoramento ou campanas no local, havendo, apenas, a descrição de uma denúncia anônima sobre eventual traficância no local e a suspeita policial em razão do suposto nervosismo do acusado que teria fugido para dentro de sua residência ao avistar a guarnição policial, de maneira que não se configurou o elemento "fundadas razões" a autorizar o ingresso no domicílio em questão. Ainda, segundo a narrativa dos policiais militares, após a realização da abordagem ao paciente, este teria confessado que tinha drogas e uma arma de fogo dentro do imóvel, bem como teria autorizado a entrada da equipe policial em sua residência.**

5. **Nessa linha de inteligência, ausente a comprovação de que houve autorização para a entrada e que esta foi livre e sem vício de consentimento, deve ser reconhecida a ilegalidade da busca domiciliar e conseqüentemente de toda a prova dela decorrente (fruits of the poisonous tree)** (AgRg no RHC 149.964/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 16/11/2021)

6. Reconhecida a ilegalidade da entrada da autoridade policial no domicílio do paciente, sem mandado judicial e sem qualquer indício concreto de que ali estivesse sendo cometido crime permanente, a prova colhida na ocasião - dois tabletes de maconha (com massa total de 1,400kg) e um revólver calibre .38 e quatro munições de mesmo calibre, de uso permitido - deve ser considerada ilícita. Assim, mantém-se a decisão que concedeu a ordem, de ofício, para absolver o paciente, em razão da ilicitude das provas apreendidas no referido ato.

7. Agravo regimental do Ministério Público do Estado de Goiás a que se nega provimento. (AgRg no HC 770572 / GO, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA, Data do Julgamento 06/12/2022, Data da Publicação/Fonte DJe 14/12/2022).

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DAS PROVAS COLHIDAS NO DOMICÍLIO DO RÉU. FLAGRANTE. AUSÊNCIA DE MANDADO. DENÚNCIA ANÔNIMA/COMUNICAÇÃO APÓCRIFA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ORDEM CONCEDIDA. 1. É pacífico nesta Corte o entendimento de que, nos crimes permanentes, tal como o tráfico de drogas, o estado de flagrância se protraí no tempo, o que, todavia, não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, se está ante uma situação de flagrante delito 2. Conforme entendimento firmado por esta Corte, **a mera denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio indicado, estando, ausente, assim, nessas situações, justa causa para a medida.** 3. Não havendo, como na hipótese, outros elementos preliminares indicativos de crime que acompanhem a denúncia anônima, inexistente justa causa a autorizar o ingresso no domicílio sem o consentimento do morador, o que nulifica a prova produzida. 4. Habeas corpus concedido para reconhecer a nulidade das provas colhidas mediante violação domiciliar. (HC n. 512.418/RJ, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 26/11/2019, DJe de 3/12/2019.)



Apelação nº. 0803817-76.2023.8.19.0083 **PJe**
Órgão: JAPERI 2ª VARA

FLS.15

Portanto, constatada a ilegalidade do ingresso dos policiais na residência do apelante sem prévia autorização judicial, devem ser declaradas ilícitas as provas colhidas na operação e derivadas destas.

À vista do exposto, **DOU PROVIMENTO ao recurso** para declarar a nulidade das provas obtidas por meio do ingresso no domicílio do réu, bem como de todas as que delas derivaram e, conseqüentemente, absolver **VAGNER DOS SANTOS MORAIS** da imputação contida na denúncia.

É como voto.

Rio de Janeiro, na data constante da assinatura digital.

Desembargador **JOAQUIM DOMINGOS DE ALMEIDA NETO**
Relator